

1500377-39.2019.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino. Assim, verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 é misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, todas as condutas nele descritas, separadas ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracaí-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500377-39.2019.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500377-39.2019.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, 2366599/2019 - DEL.POL.MARACAI, 9157141 - DEL.POL.MARACAI, 569/19/112 - DEL.POL.MARACAI, 2366599

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GILMAR DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Gilmar da Silva foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, tinha em depósito, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, vinte e três porções de maconha, com peso aproximado de 17g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 25/29.

O acusado foi notificado (fl. 135) e apresentou defesa preliminar (fls. 121/127).

A denúncia foi recebida em 31/08/2020- fl. 138.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e interrogado o acusado (fls. 171/173 e 223/224).

Em Memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da Ação Penal nos termos da denúncia (fls. 236/241).

A defesa, em Alegações Finais, asseverou a inexistência de denúncia anônima, nulidade do auto de prisão em flagrante. Defendeu que o modo em que embalada e a quantidade de drogas apreendidas não são indicativos da traficância. Pontuou que o acusado é primário, de bons antecedentes, com trabalho lícito e residência e não existe prova nos autos de sua periculosidade. Encerrou pela absolvição (fls. 244/251).

Relatei. Decido.

De saída, não há que se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante pois a situação fática delineada nos autos aponta que a polícia militar, em patrulhamento, ciente da existência de denúncias sobre tráfico de entorpecentes na residência do acusado, realizou prévia campana para verificar a veracidade das informações prestadas pelo denunciante e visualizou o réu realizando a mercância de entorpecentes.

No que concerne à entrada policial na residência do réu, oportuno lembrar, que, nas hipóteses de flagrante em crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, cuja consumação se protraí no tempo, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, conforme Tema 280 do Supremo Tribunal Federal:

"Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio ? art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos ? flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ? a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE

603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Inexiste, portanto, a aventada nulidade do auto de prisão em flagrante.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, laudo definitivo de fls. 230/232, bem como pela prova oral, coligida sob o crivo do contraditório. A autoria pelo conjunto probatório.

Gilmar da Silva, réu, perante a autoridade policial (fl. 11), permaneceu em silêncio. Durante a instrução, afirmou que, na época dos fatos, os policiais disseram que viram que o depoente tinha entregado algo para um ciclista mas isso não aconteceu. Tinha acabado de sair da casa da Jéssica, pegado uns R\$ 20,00 para pedir um lanche, momento em que foi abordado na frente de casa, e pelo fato de estar meio drogado/assustado, acabou saindo correndo. Pegaram o depoente, levaram pra casa e encontraram a droga. Logo em seguida, o lanche chegou, os R\$ 20,00 tinham sido entregues pra Marcia, pra comer lanche. Não ocorreu nada de entregar algo para ciclista. Apreenderam 23 porções de droga na residência, pagou R\$ 150,00. Tinha acabado de receber dinheiro por conta dos serviços de servente de pedreiro e comprou a droga. Comprou o que ia usar e não sobrou dinheiro. Consegue usar as 23 porções por uma semana. Pediu dinheiro na Lola. Não conhece os policiais que o apreenderam. Acredita que não tenham nada contra o depoente. Comprou as drogas em Tarumã, não conhece o vendedor.

Luiz Roberto dos Santos Cortez, testemunha de acusação, em juízo, apresentou depoimento semelhante ao depoimento prestado durante inquérito policial (fl. 06), declarou que trabalha em Paraguaçu Paulista e estava exercendo atividade delegada no município de Maracaí juntamente com outro policial. Quando faziam o policiamento sobre a área central, foram abordados por um rapaz, que informou sobre comércio de drogas. Segundo ele, o comércio estava sendo realizado próximo ao mercado Avenida, no centro da cidade de MARACAÍ. Disse as características do rapaz, que estava com uma camiseta do "Bob Marley". Chamava-se Gilmar, Gilmarzinho, que era moreno e alto. Fizeram patrulhamento das proximidades, e começaram a visualizar, estrategicamente, para apurar se, realmente, o tráfico estava sendo realizado. Observaram um rapaz sentado, em frente a uma residência e ficaram observando. Um rapaz de bicicleta parou, conversaram um certo tempo, Gilmar entrou num bar, logo saiu, entregou algo, recebeu alguma coisa em troca e colocou algo no bolso. Após alguns minutos, a situação se repetiu do mesmo modo, com uma bicicleta chegando ao local. Decidiram aborda-lo. Explicou que é difícil chegar despercebido ao local, e, quando se aproximaram, ele viu a viatura, já ficou estranho e empreendeu fuga. O parceiro do depoente desembarcou da viatura e seguiu atrás dele, e, por, mais ou menos uns 250 metros, já conseguiu abordar o acusado. Não foi localizado nada com ele, salvo engano, estava com celular e não tinha nada de ilícito com ele. Viram que realmente estava com uma camiseta do Bob Marley, chamava-se Gilmar e as características coincidiam com as características informadas pelo denunciante. O local parece um bar mas, na verdade, era a residência onde ele estava residindo. Verificaram que na residência tinha uma embalagem de vidro com mais de 20 entorpecentes. A residência estava com a porta aberta, era uma garagem sem quintal, a janela é praticamente na calçada. O vidrinho estava próximo ao batente, estava muito fácil para ele pegar e já distribuir. Quando encontraram entorpecentes, adentraram na casa e verificaram todo o local. Ele negou que estava vendendo, que dormia no local, e, às vezes, a namorada dormia com ele. Segundo ele, a droga era para uso pessoal. Verificou duas negociações realizadas por Gilmar, foram realizadas com duas bicicletas. O local de negociação estava a menos de um metro da casa de Gilmar, é uma garagem sem portão, as drogas estavam em ponte de vidro, logo na entrada da casa. Estavam embaladas em papel transparente, também encontraram papel alumínio. A casa tinha mobília, estava residindo no local.

Rodrigo Cintra Nunes, testemunha arrolada pelo autor, em juízo, apresentou depoimento semelhante ao depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 05), declarou que estava realizando patrulhamento pela cidade, juntamente com o cabo Cortez, receberam denúncia de que Gilmarzinho estaria na frente da residência dele, comercializando maconha. A denunciante residia próximo à ele e não quis se identificar. Passou as características dele, as vestes dele. Fizeram breve visualização do local em que estava comercializando drogas. Realmente, constataram que ele estava vendendo drogas. Viram indivíduos parando com bicicleta e pegando maconha com ele. Ele pegava o dinheiro, pega a droga, voltava, entregava e a pessoa saía. Em uma dessas oportunidades, tentaram abordar Gilmarzinho. Porém, o acusado, ao ver a viatura policial, tentou correr, foi necessário o uso de força física para conte-lo pois andaram por cerca de 200 metros para tentar conte-lo. Localizaram um celular com ele. Fizeram revista no interior do imóvel, localizaram 23 porções de maconha, já embaladas para comércio e R\$ 20,00. Foi dado voz de prisão e conduzido ao plantão policial. Não trabalha em Maracá, foi a primeira vez que teve contato com o acusado, porém, em contato com policiais locais, eles mencionaram que já tinham recebido várias denúncias de tráfico de entorpecentes, inclusive, foi apreendido quando era menor de idade.

Jéssica Helena Naziazeno da Rosa Silva, testemunha de defesa, disse que Gilmar é marido de sua sobrinha, é apenas usuário de drogas. Atualmente, ele trabalha, e, na época dos fatos, era servente de pedreiro.

Marcia Ribeiro Guedes, testemunha de defesa, declarou que Gilmar da Silva é usuário de drogas e ele tem emprego fixo.

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor.

Reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino. Assim, verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 é misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, todas as condutas nele descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal. Em outras palavras, o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização da droga.

O que demonstra a prática do tráfico ilícito de drogas é o dolo do agente de transferir ou repassar a droga a usuários, nos termos de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos presentes no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Eis o que estabelece o artigo 33 da Lei de Antidrogas:

"Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Destarte, para a configuração do crime em apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que afasta a exigência de se verificar a "traditio" para consumação do delito (TJSP, Apelação Criminal 1506353-79.2020.8.26.0228, Des. Klaus

Marquelli Arroyo, j. 16/11/2020).

No caso dos autos, a forma de acondicionamento e a quantidade de droga apreendida permitem concluir que não se destinava ao uso próprio, restando bem evidenciado o tráfico.

Não se descure, por fim, no aspecto, que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito o ônus probatório, cabendo, portanto, à defesa, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, na hipótese, predito ônus probandi - pela defesa - não foi satisfeito (CPP, art. 156).

Nesse sentido:

"SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C O ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A VERSÃO EXCULPATÓRIA DO ACUSADO - LOCAL PONTO DE VENDA DE DROGAS - QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, BEM COMO CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO, POLICIAIS QUE PRESENCIARAM O RECORRENTE EM ATITUDE TÍPICA DE VENDA DE ENTORPECENTES, NÃO SE COADUNAM COM USUÁRIO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO LOCAL DO CRIME - DESCABIMENTO - CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PARA TRAFICANTE OCASIONAL - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO FATORES QUE NÃO SE COADUNAM COM AQUELE QUE PRÁTICA O CRIME PELA PRIMEIRA VEZ - RÉU PRESO, APÓS SER SOLTADO POR ESTE PROCESSO, POR TRÁFICO. PENAS E REGIME BEM DOSADOS - RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal 0090612-04.2018.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

Nunca é demais lembrar que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente, quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Confira-se:

"PROVA - Depoimento de policiais - Valor: Reveste-se de idoneidade a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, mesmo que constituída por depoimentos de policiais, não sendo possível desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da repressão penal".
(TACrimSP - Ap. nº 1.370.051/1 - Araraquara - 12ª Câmara - Rel. Barbosa de Almeida - J. 29.3.2004 - v.u.).

Passo à dosimetria da pena.

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não possui antecedentes. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas não foram apreendidas em quantidade elevada a ensejar o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de

Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, permanece a reprimenda em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na derradeira fase da dosimetria, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois as circunstâncias da abordagem e o relato dos policiais militares acerca do envolvimento do acusado com a traficância indicam a dedicação a atividades criminosas. Além disso, conforme se verifica às fls. 31/32, quando adolescente, o acusado já praticou vários atos infracionais, o que demonstra a sua dedicação a atividades criminosas, sendo inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

"Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas e não questionadas. Dosimetria que comporta reparos. Pena-base elevada em um quinto diante da quantidade e qualidade das drogas e pelo cometimento de atos infracionais durante a menoridade. Impossibilidade de utilização de atos infracionais como Maus Antecedentes. Precedentes. Reduzida quantidade. Reforma para o mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça Negativa de incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 fundada na persistência delitiva do apelante. Registro de atos infracionais e existência de ações penais em curso. Dedicação a atividades criminosas, de modo a obstar a incidência do redutor atinente ao tráfico privilegiado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Regime fechado bem fixado. Inviabilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Provimento parcial do apelo". (TJSP; Apelação Criminal 1501233-83.2019.8.26.0618; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 27/05/2022)

Ausentes causas de aumento, fixo a reprimenda, definitivamente, em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR Gilmar da Silva como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado ante a gravidade concreta do delito, indicando a necessidade da imposição do regime mais rigoroso (cf. artigo 59, III, c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Ante a quantidade da pena, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal) bem como a concessão de sursis (artigo 77 do Código Penal). Além da gravidade concreta da conduta demonstrar que não seria socialmente recomendável.

Ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve recorrer em liberdade em relação a esse processo (art. 387, § 1º, do CPP).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade resta suspensa por contados benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º

do CPC. Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, no valor máximo da tabela oriunda do convênio entre OAB/DPE.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Maracai, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA